



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעת (הנתבעת שכנגד)	1	שרה נפחא ת.ז. 897678 באמצעות ב"כ עו"ד אליעזר ריזה
	נגד	
הנתבעים (הנתבע 1 התובע שכנגד)	1	אליעזר ורצברגר, ת.ז. 30073621
	2	יעקב אולבסקי, אחר E2940251
		הנתבעים 1-2 באמצעות ב"כ עו"ד סלבה רודנקו
	3	ציפורה שכטר ת.ז. 025115080
	4	מרדכי שכטר ת.ז. 323738419
		נתבעים 3-4 באמצעות ב"כ עו"ד אהרון פוגל

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם הנתבעים, או חלקם, רשאים לבנות יחידות דיור נפרדות על גבי הגג המוצמד בצמידות מיוחדת לחלק מבעלי הדירות בבית המשותף וכן על גג שייוצר מעליו. במסגרת זו יש לבחון האם ניתן לראות בתובעת כמי שנתנה הסכמה או הסכמה קונסטרוקטיבית לבניה מהסוג האמור והאם דינה של הבניה שבוצעה זה מכבר על גבי הגג המשותף להיחרס. כמו כן תבחן השאלה האם הנתבעים 3-4 פיצלו את דירתם באופן המצדיק לאסור עליהם לעשות כן.

א. עיקרי העובדות

1. עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש 30079 חלקות 96 ו-112 והממוקם ברחוב אלקנה 23 בירושלים (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף נרשם בשנת 1955 וחל עליו התקנון המצוי. כעולה מצו רישום הבית המשותף והתשריט, הבית המשותף בנוי ב-3 קומות ובו 12 תתי חלקות. קיימות 4 דירות בכל קומה. למעשה, הבית המשותף בנוי מ-4 עמודות צמודות זו לזו, כאשר לכל 2 עמודות כניסה נפרדת. עמודה ראשונה, הצפונית ביותר, מורכבת מתתי חלקות 1,5,9 (1- קומה ראשונה, 5- קומה שנייה, 9- קומה שלישית), עמודה שניה, דרומית לה- תתי חלקות 2,6,10 (2- קומה ראשונה, 6- קומה שנייה, 10- קומה שלישית), עמודה שלישית- דרומית לעמודה השנייה- תתי חלקות 3,7,11 (3- קומה ראשונה, 7 קומה שנייה, 11- קומה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלישית), ועמודה רביעית, הדרומית ביותר, כוללת את תתי חלקות 4,8,12 (4- קומה ראשונה, 8, קומה שנייה, 12- קומה שלישית). גג בשטח של 264 מ"ר (להלן: "הגג" או "הגג המשותף") מוצמד לתתי חלקות 5-12 בלבד (כלומר לכל הדירות בקומות השנייה והשלישית), שהן במקורן וכרשום בנסח, בשטח זהה של 67 מ"ר. הדירות בעמודה הראשונה והשנייה שייכות ל"כניסה ב" והדירות בעמודה השלישית והרביעית ל"כניסה א".

2. הצדדים להליך (פרט לנתבע 2) הם בעלי דירות בקומה השלישית והעליונה של הבית המשותף- התובעת היא בעלת הדירה הידועה כתת חלקה 9 הממוקמת בעמודה הראשונה (להלן: "דירת התובעת"). הנתבע 1 (להלן: "ורצברגר") הוא בעל הדירה הידועה כתת חלקה 10, הממוקמת בעמודה השנייה, בסמוך לדירת התובעת (להלן: "דירת ורצברגר"). הנתבעים 3-4 (להלן: "שכטר") הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 11 (להלן: "דירת שכטר"), בעמודה השלישית, בסמוך לדירת ורצברגר. הנתבע 2 (להלן: "אולבסקי") הוא מי שלטענתו רכש, באמצעות בתו וחתנו, מורצברגר, כמו גם מבעלי דירות נוספים בבית המשותף, את חלקם בגג המשותף ובזכויות הבניה. דירה נוספת הממוקמת בקומה השלישית היא ת"ח 12, שבבעלות ויינשטין שלמה אפרים (להלן: "ויינשטיין"), שאיננו צד להליך זה.

3. כתב התביעה המקורי הוגש כנגד ורצברגר בלבד ונטען בו כי לאחר שיבוצעו הרחבות בניה ל-3 מדירות הקומה השלישית לעבר הגג באמצעות בניית קומה נוספת- קומה רביעית (הרחבות אליהן לא מתנגדת התובעת), עתיד להיווצר גג חדש, בקומה החמישית, בו מבקש ורצברגר לבנות 4 יחידות דיור חדשות ונפרדות. עוד נטען כי ורצברגר מבקש להפוך את הרחבת דירתו בלבד בקומה הרביעית, לדירה נפרדת ועצמאית, בעוד שיתר הדירות בקומה השלישית תזכינה בהרחבה בלבד. בכתב התביעה המקורי התבקש לאסור על ורצברגר לבנות כל בניה שהיא בשטח המשותף לרבות בגג המשותף ללא הסכמת הנתבעת. בכתב התביעה המתוקן, אשר הוגש ביום 27.3.18, הוספו כנתבעים אולבסקי ושכטר. נטען בו כי לאחר הגשת כתב התביעה המקורי ותוך כדי ניהול ההליך, בנה אולבסקי בפועל יחידה נפרדת וקבועה בשטח עשרות מטרים על גבי הגג המשותף. עוד נטען כי שכטר, אשר קיבלו היתר בניה להרחבת דירתם בלבד, פיצלו בפועל את דירתם לשתי יחידות נפרדות ואף צירפו מחצית מדירתם המורחבת ליחידה שנבנתה שלא כדין על גבי הגג המשותף. **אי לכך, התבקשו הסעדים הבאים: לאסור על הנתבעים או מי מטעמם לבנות בשטח המשותף, לרבות על הגג המשותף, ללא הסכמת הנתבעים ושאר בעלי הדירות בכלל, לצוות על הנתבעים לסלק את ידם מהגג המשותף, בחלק שלגביו לא ניתן היתר בניה, כלומר מגבול דירת שכטר והלאה וכן לצוות על הנתבעים להרוס את כל אשר נבנה שלא כדין, ללא היתר בניה וללא הסכמת בעלי הדירות ולהשיב את הבניה שבוצעה בהרחבת דירת שכטר ליעודה המקורי- היינו דירה מורחבת ללא פיצול.**

4. למען שלמות היריעה יש להציג את תמונת המצב התכנונית הרלוונטית לבית המשותף: על הבית המשותף חלה בעבר תכנית 5613 (להלן: "התכנית הישנה") המאפשרת, בין היתר, להרחיב את הדירות על ידי הוספת הרחבה בצדן להרחיב את הדירות בקומה השלישית באמצעות בנית מפלס מגורים נוסף על גבי הגג המשותף,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לעבר הקומה הרביעית. ורצברגר הגיש תכנית חדשה, תכנית מתאר מקומית 101-0172221 (להלן: **"התכנית החדשה"**) אשר אושרה ופורסמה ברשומות ביום 2.12.15 (ילקוט הפרסומים 7157, כ' כסלו התשע"ו, 2.12.2015). במסגרת התכנית החדשה אושר לבטל את התכנית הישנה, לאשר בנית הרחבות ל-3 מדירות הקומה השלישית, להפוך את הרחבת דירת ורצברגר ליחידה נפרדת ועצמאית וכן לבנות עוד 4 דירות נפרדות ועצמאיות על הגג המשותף מעל קומת ההרחבה (בקומה החמישית). למעשה מדובר בהוספת 5 יחידות דיור, כאשר בבית המשותף צפויות להיות בסה"כ 17 תתי חלקות.

5. התובעת הגישה התנגדות לתכנית החדשה, אשר נדחתה בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות (להלן: **"הועדה"**) מיום 30.6.15 (ראה נספח ח' לכתב התביעה המתוקן). בין היתר נקבע כי: **"הועדה דוחה את הטענות הקנייניות שהועלו בדיון. הועדה תציין כי מדובר בטענות קנייניות אשר מוסדות התכנון אינם מוסמכים להכריע בהן, וכי יש לבררן, כפי שציין אף ב"כ המתנגדת, בפני הערכאות הרלוונטיות. הועדה מבהירה כי אין בתכנית כל קביעה ביחס לזכויות הקנייניות בתחום התכנית"**.

6. ורצברגר, מצדו, הגיש כתב תביעה שכנגד בו טען כי הנתבעת תפסה חזקה ייחודית במחסן שנמצא בצד היציאה מחדר המדרגות לגג הבניין הקיים מעל דירתה והיא מאחסנת בו את חפציה ללא הסכמת שאר בעלי הדירות תוך יצירת מפגע תברואתי. לפיכך התבקש לצוות על הנתבעת לפנות את המחסן ולאסור עליה לעשות בו שימוש ייחודי. עוד נטען כי הושגה הסכמה בין כל בעלי הדירות בעמודות בנוגע לשימוש ייחודי בגגות ביחס לכל עמודה, אולם ככל שתתקבלנה טענות התובעת כי אין כך הדבר, יש לקבוע כי היא עושה שימוש ייחודי בגג שלא כדין ולפיכך יש "לאסור עליה לתפוס בגג חזקה ייחודית ולמנוע מדיירים אחרים, ובפרט הנתבע, לעשות שימוש בגג מעל דירתה לכל מטרה סבירה, כולל בניית סוכה".

7. ביום 8.9.19 קיימתי ביקור במקום בנוכחות ב"כ התובעת עו"ד ריזה, בנה של התובעת- מר יצחק נפחא, אולבסקי וב"כ הנתבעים 1-2 עו"ד רודנקו. לביקור לא התייצבו הנתבעים 3-4, שכטר, או מי מטעמם. בביקור ניתן היה להבחין במבט מחזית הבית המשותף כי מעל דירת התובעת אין כל בניה, מעל דירת ורצברגר- הסמוכה לה, קיימת בניה המתפרשת גם אל תחומי הגג שמעל דירת שכטר בחלקה. כמו כן ניתן להבחין בתוספת בניה מעל דירת שכטר וכן מעל תת חלקה 12, בעמודה הרביעית. בביקור בגג הבית המשותף עצמו, ניתן היה לעמוד באופן ברור יותר על טיב הבניה אשר בוצעה בחלקה מעל דירת שכטר ובחלקה מעל דירת ורצברגר. מדובר ביחידה נפרדת ועצמאית לכל דבר שאינה מחוברת לדירות מתחתיה בכל צורה שהיא. בקומה השלישית, לא ניתן היה להיכנס לדירת שכטר כיוון שהייתה סגורה בעת הביקור ולא נכח, כאמור, נציג מטעמם. בקומה הרביעית (הרחבת דירת שכטר) ניתן היה להיכנס דרך דלת פתוחה לגרם מדרגות בו ניתן היה להבחין בשתי דלתות נפרדות. בקומה השלישית, במעלה חדר המדרגות ובסמוך לפתח היציאה לגג, נצפה מדף צר המכיל ציוד רב.

ב. עיקרי טענות התובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. התובעת טוענת כי הגג החדש שעתיד להיווצר לאחר בנייתן של ההרחבות לדירות בקומה השלישית (אליהן אין היא מתנגדת) יהיה "גג חדש" השייך לכל 12 הדירות בבית המשותף. לפיכך, לטענתה, בניה או שימוש ב"גג החדש" דורש את הסכמת כל בעלי הדירות ולא רק בעלי תתי חלקות 5-12 אליהם צמוד הגג הקיים. בהתאם נטען, כי לשם בנית יחידות דיור נוספות ועצמאיות, שאינן בגדר "הרחבת דירה קיימת" יש צורך בקבלת הסכמת כל בעלי הדירות (100%) כאשר הסכמה זו צריכה להיות מפורשת ולא משתמעת. לטענה, הסכמות נדרשות אלו אינן בנמצא. התובעת מדגישה כי על אף שהגג המשותף צמוד לתתי חלקות 5-12, אין כל הצמדה של זכויות הבניה לדירות אלו, כך שזכויות הבניה שייכות לכל דירות הבית המשותף, כולל דירות הקומה הראשונה. לטענת התובעת, הנתבעים מבקשים לממש ולנצל את כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות באופן שימנע משאר בעלי הדירות לבקש תוספות בניה משלהם.

9. לטענת התובעת בסיכומיה, במהלך ההליך התברר כי אולבסקי סיפק לורצברגר ושכטר שירותי בניה ואולי גם שילם להם כסף, ואילו בתמורה הם נתנו לו את הזכות לבנות בגג שמעליהם וכן שותפות מלאה בביצוע הבניה בפועל. נטען כי ורצברגר הוא שניצב בחזית כמי שהגיש את התכנית החדשה ואת הבקשות להיתרי בניה מכוחה כאשר בפועל הרוח החיה היה אולבסקי עצמו. לטענתה, מדובר בניסיון לביצוע מעין "עסקת קומבינציה" – מתן שירותי בניה תמורת זכויות בניה ושטח לבניה. אלא, שלטענת התובעת, זכויות הבניה והשטח לבניה על הגג שנתנו כביכול שכטר וורצברגר לאולבסקי כלל לא בבעלותם וממילא הם אינם זכאים למכור אותם. בנוסף, נטען כי הדין אינו מאפשר מכירת שטחים משותפים בנפרד מדירות.

10. לטענת התובעת, מימוש התכנית החדשה ובניה בהתאם לה אף תסב נזקים משמעותיים לדירתה – פגיעה בפרטיות, ירידת ערך, תשלום היטל השבחה שיחול עליה תוך העדר זכאות לפטור נוכח ביטולה של התכנית הישנה, פגיעה ביכולה לבנות סוכה על הגג באופן נוח וסמוך לדירתה כבמצב הנוכחי ומניעת אפשרות לבניה עתידית על פי תמ"א 38.

11. התובעת מדגישה כי הנתבעים ביצעו בניה שלא כדין ובהעדר הסכמות, תוך כדי ניהול ההליך ובעת שהמפקח הפנה אותם לנהל מו"מ והכל תחת גבה של התובעת. נטען כי בכך יש משום חוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים המעיד על התנהלותם של הנתבעים.

12. ביחס לשכטר נטען כי בהתאם לתכנית החדשה ניתן להם היתר להרחיב את דירתם אלא שבפועל נוצל ההיתר לפיצולה וליצירת שתי יחידות נפרדות שלא כדין. התובעת טוענת כי בניגוד לנטען על ידי שכטר, שהחליטו שלא לממש את מלוא יכולת הבניה לפי ההיתר אלא לבנות רק חלק ממה שניתן היה על פי ההיתר, בפועל בנו שכטר יחד עם אולבסקי שתי יחידות נפרדות – אחת בשימוש שלהם והאחרת בשימוש של אולבסקי. נטען כי גם החצי שבשימוש של שכטר פוצל לשתי יחידות. לטענת התובעת, פיצול יחידה לשתיים מוביל לריבוי דיירים ופוגע בערכן של הדירות האחרות. נטען עוד כי פיצול זה אסור גם מכוח סעיף 2 לתקנון המצוי, האוסר ביצוע שינויים בדירה העלול לפגוע בערכה של דירה אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. עיקרי טענות הנתבעים 1-2

13. לטענת הנתבעים 1-2, לפני שנים הושגה הסכמה בין בעלי הדירות לפיה החלק של הגג המשותף מעל כל אחת מ-4 העמודות, לרבות זכויות הבניה בו, יהיה שייך קניינית לעמודה שמעליה הוא נמצא. נטען כי לאור הסכמת הדיירים בדבר שימוש ייחודי בגגות מעל העמודות, אין לתובעת כל זכות שימוש בגגות מעל ל-3 העמודות האחרות ואין לה כל זכות להתנגד לבניית שתי הקומות מעל עמודות אלו בהתאם לתכניות שאושרו. נטען כי מדובר בהסכם בע"פ שהיה קיים משך שנים בהתנהגות כאשר בהמשך עוגן גם בכתב, הכל ברוח ההבנות שהיו קיימות. לטענתם, התפיסה הקיימת, אשר אוששה מאוחר יותר גם בכתב, היא כי הגגות מעל כל עמודה ועמודה שייכים לאותה עמודה וההתחשבות לגבי הבנייה עליה היא בין דיירי אותה עמודה בלבד. נטען כי כל ההתחשבות ביחס לזכויות בניה נעשתה גם היא במסגרת ההסכם שנחתם בין בעלי הדירות כאמור וכי העובדה שלאורך שנים לא הייתה טענה מצד התובעת מעידה על כך.

14. נטען כי מבחינה תכנונית ובהתאם ל"מבחן הסמיכות הפיסית" יש לראות את בנית היחידות הנפרדות כ"הרחבה" שכן אין אפשרות להרחבת דירות בקומה השנייה של הבניין לצדדים והרחבתן באמצעות הוספת יחידות בקומה הרביעית מהווה את האפשרות היחידה לאזן את התוספות לדירות אלו. נטען כי העובדה שהגג הוצמד גם לדירות בקומה השנייה מלמדת כי הייתה כוונה וציפייה כי גם דירות אלו יוכלו לקבל הרחבות.

15. לטענת הנתבעים 1-2 יש לראות בתובעת כמי שנתנה הסכמה שכן ילדיה של התובעת, עמם נפגש אולבסקי, הסכימו למימוש התכנית החדשה אולם ביקשו כי כל עוד התובעת מתגוררת במקום, לא תבוצע הבניה. נטען כי היות שהתובעת כבר אינה גרה במקום, אין דבר שיכול להפריע ליישום ההסכמות. לחלופין נטען כי יש לראות בה כמי שנתנה הסכמתה הקונסטרוקטיבית נוכח אי התנגדותה לתכנית הישנה ולבניית קומה נוספת כהרחבה וכיחידת דיור נפרדת לתת חלקה 12. לטענתם, התובעת לא התנגדה להרחבת ת"ח 12 ואף לא בדקה אם היא פוצלה. נטען כי הסכמה קונסטרוקטיבית יכולה להתייחס גם לבניית יחידה נפרדת ולא רק להרחבה.

16. מכל מקום נטען כי גם אם הסכמתה הקונסטרוקטיבית אינה חלה על הוספת דירות בקומה הרביעית, יש לדחות את התביעה מכוח עקרון תום הלב ו"זעקת ההגינות" ולאפשר לשאר הדיירים לבנות את הקומה הרביעית על אף התנגדותה של התובעת. בהקשר זה נטען כי יש להביא בחשבון את העדר הפגיעה בתובעת לעומת הפגיעה הרחבה שלטענתם תגרם לשאר בעלי הדירות כתוצאה ממניעת בניית הקומה הרביעית, את שיעור זכויותיה של התובעת בגג לעומת שיעור זכויות שאר בעלי הדירות ואת העובדה כי הנזק הנטען על ידי התובעת ניתן לתיקון באמצעות שינויים תכנוניים או פיצוי כספי.

17. הנתבעים 1-2 מכחישים את טענות התובעת לפיהן מימוש התכנית החדשה יפגע בדירתה וטוענים כי טענותיה נעדרות בסיס. נטען כי מכל מקום התכנית החדשה מעלה את ערך דירת התובעת, הן לאור חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה והוספת ממ"דים ומעלית והן לאור מתן אפשרות להרחבת דירת התובעת על ידי הוספת חדר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נוסף, מרפסת ומרפסת סוכה. נטען עוד כי התכנית החדשה אינה מבטלת את התכנית הישנה בכל הנוגע להרחבת דירת התובעת ולפיכך אינה אמורה לבטל פטור, אם קיים, מהיטל השבחה.

18. מוסיפים וטוענים הנתבעים 1-2 כי מכוח עקרון תום הלב מנועה התובעת מלהתנגד לשימוש ברכוש משותף על ידי אחרים. נטען כי התנגדותה איננה עניינית, נעוצה בטעמים שכלל לא הוכחו, כאשר בין נימוקיה אף קיימת סתירה פנימית. לטענת הנתבעים, זכות התובעת להתנגד אינה יכולה להיות סתמית אלא כפופה לעקרון תום הלב, כאשר אין להתעלם מאינטרסים של הצד השני. נטען, כי המפקחת מוסמכת לאשר בניה ברכוש משותף גם בהעדר הרוב הדרוש כאשר טעמי ההתנגדות נעוצים בחוסר תום לב. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי יש לזקוף לחובתה של התובעת את העובדה כי לא הגישה תצהיר ולא העידה בהליך, נטען כי מדובר בעדה מרכזית ולפיכך יש להיעדר עדותה משקל יתר.

19. לטענת הנתבעים 1-2, התכנית החדשה הוגשה על ידי ורצברגר בשיתוף פעולה עם אולבסקי. הנתבעים מכחישים בכתב הגנתם את הטענה הנוגעת לבניית יחידות נוספות שלא כדין. לטענתם, הבניה שביצעו נעשתה במסגרת התכניות שבתוקף ובגבולות ההרחבות להן הסכימה גם התובעת. בהקשר זה נטען כי גם הבניה לגביה נטען שבוצעה תוך כדי ההליך ושלא כדין, נעשתה בהתאם לאותן תכניות מאושרות, כאשר הבניה על חלק הגג שמעל דירת שכטר נעשתה בגבולות היתר הבניה שניתן והבניה על חלק הגג המשותף שמעל דירת ורצברגר, בוצעה בגבולות היתר הבניה שצפוי להינתן, וזאת מחמת אילוץ ולשם הגנת הגג מרטיבות הנובעת מי גשמים ושמירה על המראה האסתטי של הבניין. בכתב ההגנה נטען כי לורצברגר אין כל קשר לבניה שבוצעה. עוד נטען כי טרם נעשה שימוש בבניה. לטענת הנתבעים סעד של הריסה איננו מידתי וכי די בכך שיינתן צו איסור שימוש עד לקבלת היתר בניה כדין.

20. ביחס לתביעה שכנגד נטען כי הנתבעת שכנגד תפסה חזקה ייחודית במחסן ומאחסנת בו את חפציה ללא הסכמת בעלי הדירות כדין וכי היא עושה שימוש ייחודי בגג שמעל דירתה, לרבות לצורך בניית סוכה.

ד. עיקרי טענות הנתבעים 3-4 (שכטר)

21. לטענת שכטר, למרות שהבית המשותף בנוי על 2 חלקות הוא מעולם לא אוחד בתכנית בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 (להלן: "**חוק התכנון והבניה**"). לפיכך, נטען, כי דירות התובעת והנתבעים אינן ממוקמות על אותה חלקה, וזאת כאשר הרכוש המשותף של כל חלקה וחלקה שייך לבעלי הדירות באותה חלקה בלבד. עוד נטען כי דירות התובעת ושכטר אף ממוקמות בכניסה אחרת כאשר כל אחת מהכניסות מנהלת בנפרד את הרכוש המשותף שבתחומה. לפיכך, נטען כי אין בין התובעת לשכטר כלל יריבות וכי מדובר בתביעה טרדנית וקנטרנית שדינה להיות מסולקת על הסף. עוד נטען כי הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**" או "**חוק המקרקעין**"), המקנה סמכות למפקחת לדון בתביעות ביחס לסכסוך בין בעלי דירות בבתי משותפים, מתייחסת לבית משותף שנבנה על חלקה אחת בלבד ועל כן יש לדחות את התביעה גם בהעדר סמכות עניינית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. כטענה חלופית לכך שמדובר בחלקות נפרדות ולפיכך אין בין הצדדים יריבות, נטען כי מדובר בבית מורכב שאינו דורש רישום בתקנון או קביעת מפקח על רישום מקרקעין לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין, שכן מדובר בחלקות נפרדות. לטענתם, סעיף 59 לחוק המקרקעין מתייחס רק למצב בו הבית המשותף בנוי על גבי חלקה אחת. מכל מקום נטען כי עובדתית כל כניסה מתנהלת בנפרד ולה זכויות בניה משלה, גם מן הבחינה הקניינית. לתמיכה בטענותיהם מפנים שכטר לרע"א 101/86 קדמאני נ' אבו אלחאג', פד"י מ(1) 613.

23. לגופו של עניין, שכטר טוענים כי בנו בהתאם להיתר הבנייה שניתן להם ובהסכמת התובעת ומכחישים כי בנו יחידות נפרדות וחרגו אל תוך הגג המשותף בסטייה מן ההיתר. נטען כי התובעת לא הביאה כל ראיה לביסוס טענת ה"פיצול". שכטר מציינים כי קיר פנימי בדירתם הוסט, אולם נטען כי מדובר בשינוי פנימי בלבד שאינו מצריך היתר בניה נוסף. שכטר סבורים כי הם נקלעו לסכסוך לא להם. לטענתם, הם בנו רק על מחצית שטח הגג שמעל לדירתם, בהתאם להיתר הבניה, כאשר לגבי יתר השטחים שמעל דירתם סילקו משם ידם לטובת הנתבעים 1-2. נטען כי הבניה שהיא מעבר להרחבת דירתם לא נעשתה על ידם והיא אף איננה בשימוש. שכטר טוענים כי בנו את ההרחבה לדירתם בהיקף נמוך מזה שאושר להם לפי היתר הבניה, אולם אין כל מניעה כי יממשו את היתר הבניה רק בחלקו וכי מכל מקום התובעת נתנה הסכמתה להרחבת דירתם בהתאם להיתר.

ה. עיקרי התייחסות התובעת לטענות הנתבעים ולתביעה שכנגד

24. התובעת טוענת כי לא הוכח קיומו של הסכם המחלק את הגג בין בעלי הדירות להן מוצמד הגג לרבות זכויות הבניה עליו. לטענתה, עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב ואין הוכחה לקיומו של מסמך כאמור. נטען כי ההסכם לא הוצג חתום בחתימות בעלי הדירות שלפי הטענה חתמו עליו, הוא אינו מנוסח כלל כהסכם לחלוקת מקרקעין, נעדר מסוימות ואין בו פרטים בסיסיים כגון פרטי הבניין, תנאים גבולות ותשריט. אין גם אחריות לדיווח לרשויות המקרקעין. נטען כי הרב קראוס, אשר לטענת הנתבעים "שמר" על ההסכם, כלל לא זומן להעיד בהליך והדבר צריך להיזקף לחובתם. לטענת התובעת, ההסכם הנטען גם אינו עולה בקנה אחד עם הסכם מאוחר יותר, עליו חתום אולבסקי, לפיו רכש כביכול מורצברגר זכויות בלתי מסוימות בגג בלבד. לטענתה, ההסכם האחרון בכתב אינו מתיישב עם ההסבר בעל פה שמספקים הנתבעים בדבר קיומו של הסכם בין בעלי הדירות בעמודות. מכל מקום נטען כי אף אם חלק מבעלי הדירות חתמו על הסכם, הסכם זה לא יכול להיות בעל תוקף משפטי בשל החסרים הקיימים בו וממילא לכל היותר חתמו עליו- אף לשיטת ורצברגר ואולבסקי, 8 בעלי הדירות להן צמוד הגג כאשר חלוקת אחוזי הבניה צריכה להיעשות בין 12 בעלי הדירות.

25. התובעת טוענת כי לא הייתה חלוקה בין הגגות גם לצורך שימוש ייחודי, כי לא עשתה בפועל כל שימוש ייחודי בגג שמעל דירתה וכי ממילא לא ניתן ללמוד משימוש ייחודי על זכויות קנייניות והצמדות.

26. עוד טוענת התובעת כי אין בהסכמתה להרחבת הדירות לפי התכנית הישנה ואף לא להרחבתן לפי התכנית החדשה משום הסכמה קונסטרוקטיבית ביחס לבניית יחידות הדיור הנפרדות לפי התכנית החדשה, משני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טעמים: ראשית, נטען כי הסכמה קונסטרוקטיבית יכולה להיחשב ככזו במקרה שהשכן כבר קיבל היתר בניה או בנה בפועל וכי במקרה הנדון היא לא בנתה ולא קיבלה היתר בניה ולכן אין הסכמה כזו. ממילא, נטען, כי לפי סעיף 71ב בעל דירה נחשב כמי שנתן הסכמתו הקונסטרוקטיבית אם בנה "הרחבה דומה" ובמקרה הנדון אי אפשר לטעון להרחבה דומה, שכן לתובעת לכל היותר אפשרות לבנות הרחבה לדירתה ולא יחידה נפרדת. שנית, נטען כי הסכמה קונסטרוקטיבית רלוונטית לפי סעיף 71ב לחוק המקרקעין רק להרחבה של דירה ולא ליחידות נפרדות, לשם כך דרישת הסכמת כל בעלי הדירות נותרה בעינה. התובעת מכחישה כי היא או בניה נתנו לאולבסקי הסכמה לבניה לפי התכנית החדשה.

27. התובעת טוענת כי הרחבה צריכה להיות סמוכה פיסית ורצופה לדירה המורחבת ולא מנותקת. התובעת עומדת על טענתה כי טעמי ההתנגדות שלה אינם סתמיים ומדגישה כי בראש ובראשונה מבקשים הנתבעים להשתמש ולבנות על גבי שטח ששייך גם לה ולו שווי ניכר ובכך הם פוגעים בזכויותיה ובקניינה.

28. ביחס לטענות שכטר נטען כי אין להן כל סימוכין בחוק ובפסיקה וכי צו רישום הבית המשותף מעיד על כך שכל הגגות שייכים לדירות הבית המשותף ללא חלוקה לפי חלקות. נטען כי שכטר נמנעו מלהגיע לביקור במקום ולבחון את דירתם והפיצול שנטען כי נעשה בה וזאת יש לזקוף לחובתם.

29. ביחס לתביעה שכנגד נטען כי מדובר בתביעה שהוגשה בחוסר תום לב. נטען כי "המחסן" הנטען הוא למעשה מדף פתוח בשטח של כ-10 מ"ר, הממוקם בגובה הגג סמוך ליציאה ממנו. נטען כי הנתבעת שכנגד עושה שימוש בשטח זה כבר למעלה מ-50 שנה ברציפות ומעולם לא פנו אליה שכנים בתלונה על כך. עוד נטען, כי מדובר בשימוש שניתנה לגביו הסכמה מכללא וכי גם הנתבע עצמו עושה שימוש בשטח זה ומאחסן בו את חפציו.

1. דיון והכרעה

30. ראשית אפתח בדיון בטענות המקדמיות בדבר היעדר סמכות עניינית והעדר יריבות, אשר הועלו על ידי שכטר ואשר דינן להידחות. סעיף 142 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: "**(ב) שני בתים או יותר שבכל אחד מהם יש דירה אחת או יותר והבתים הוקמו על חלקה או חלקות שאינן ניתנות לחלוקה באופן שכל בית יעמוד על חלקה נפרדת, ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף; (ג) שני בתים או יותר שיש להם מתקנים משותפים, ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף (ההדגשות לא במקור).** סעיף 57 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 מוסיף וקובע כי: "**(א) הוגשה למפקח בקשה לרישום שני בתים או יותר כבית משותף אחד, כאמור בסעיף 142(ב) לחוק, וראה המפקח כי מהתשריט שצורף לבקשה נובע, על פני הדברים, שהחלקה או החלקות שעליהן הוקמו הבתים אינן ניתנות לחלוקה כאמור באותו סעיף, ייתן צו רישום...; (ב) לא ראה המפקח כאמור יורה למבקש להמציא את הבקשה למוסד התכנון... ולא ייתן צו רישום אלא אם קבע מוסד התכנון כי החלקה או החלקות אינן ניתנות לחלוקה...".**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. הכלל הקבוע בסעיפים הללו הוא כי כל בית משותף יירשם על חלקה נפרדת. ההיגיון בצדו של כלל זה הוא ברור - יחסי השיתוף בין בעלי הדירות יוצרים תלות קניינית. על כן, ככל שהדבר ניתן, מן הראוי והנכון לכלול כמה שפחות בעלי דירות התלויים זה בזה מן הבחינה הקניינית, ולהימנע מהסרבול הכרוך ברישום מספר רב של בניינים ודירות יחד (י. ויסמן קניין, בעלות ושיתוף, 358 להלן: "**וייסמן**"). על מורכבותו של הבית המשותף ר' עוד מ. דויטש, קניין, כרך א' 650-649. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם החלקות עליהם בנוי הבית אינן ניתנות לחלוקה או שקיימים מתקנים משותפים, באופן המאפשר לרשום את הבית המשותף ככזה החולש על פני יותר מחלקה אחת. במצב דברים זה אין כל צורך או תנאי לבצע בחלקות פעולת איחוד תכנונית-**"הבית יכול לעמוד על חלקה אחת ויכול גם שיעמוד גם על כמה חלקות. אין מניעה לרשום בית העומד על כמה חלקות ואין צורך לבצע בהן פעולת איחוד..."** (ראה א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 31- להלן: "**אייזנשטיין**").

32. במקרה הנדון, מדובר בחלקות שאינן ניתנות להפרדה או שקיימים מתקנים משותפים באופן המאפשר את רישומו של הבית המשותף על פני שתי חלקות. שנרשם הבית המשותף באופן זה הרי שמדובר בבית משותף לכל דבר ועניין אשר פרק ו' לחוק חל עליו, ובכלל זה סעיף 72 הדן בסמכות המפקח על רישום המקרקעין. היות שכך, הרי שמן הבחינה הקניינית הרכוש המשותף אשר לא הוצמד לדירות או חלקן מהווה רכוש משותף של כל הדירות, והרכוש המשותף המוצמד בצמידות מיוחדת שייך לדירות אליהן הוצמד ואין נפקא מינא אם אלו בנויות פיסית על גבי החלקה האחת עליה עומד הבית המשותף או האחרת ואם הדירות שייכות לכניסה האחת או האחרת.

33. גם הטענה כי מדובר בבית מורכב אשר אינו מצריך, לשם הכרה בו ככזה, רישום בתקנון או את קביעת המפקח מכוח סעיף 59 לחוק המקרקעין- אין בה ממש. הטענה כי סעיף 59 מתייחס רק למצב בו הבית המשותף בנוי על גבי חלקה אחת, היא טענה בעלמא שאיננה מבוססת על דבר. כאמור, שעה שנרשם הבית המשותף חל עליו פרק ו' לחוק על כך הכרוך בכך ובכלל זה גם האמור בסעיף 59 ביחס לקיומו של בית מורכב. מכל מקום, בהעדר רישום בתקנון הבית המשותף של הבית כבית מורכב, הרי שלכל היותר מוסמך המפקח להורות על הפרדת ניהול ולא על הפרדה קניינית והצמדות של חלקי הרכוש המשותף שבו (ראה: רע"א 2575/18, **יעקובסון נ' לוי** [פורסם ב"נבו"], 25.3.19). פסק הדין ברע"א 101/86 **קדמאני נ' אבו אלחאג'**, פד"י מ(1) 613, אליה הפנו שכטר, כלל איננו רלוונטי למקרה שלפנינו. באותו מקרה נדונה מחלוקת ביחס לפירוק שיתוף במקרקעין ונקבע כי ניתן לבצע פירוק שיתוף ביחס לחלקה אחת בלבד, גם אם המלון משתרע על פני מספר חלקות הרשומות בנפרד במרשם המקרקעין, שכן מדובר ב"יחידות רישום" נפרדות. במקרה דנן "יחידת הרישום" היא הבית המשותף כולו, על אף שהוא משתרע על פני מספר חלקות שכן הוא נרשם כדן כבית משותף אחד ובהתאם נגזרות זכויות בעלי הדירות בו ברכוש המשותף ולא בהתאם לחלקות עליהן הוא ניצב.

ז. רף ההסכמות הנדרש לביצוע תוספות בנייה בבית משותף – כללי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. בניית יחידת דיור חדשה ברכוש המשותף, משמעה גריעת חלק מהרכוש המשותף והעברת הבעלות עליו מבעלי הדירות. הכלל לפיו הצמדת רכוש המשותף לדירה פלונית דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות קבוע בסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") – "... אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (ראה גם ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד (2) 810, 807; רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה (3) 385, 402).

35. במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629), ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראת סעיף 62 לחוק כאשר מדובר בהרחבת דירה קיימת וזאת על מנת למצוא בעיות לצפיפות המגורים (ראה בהקשר זה דברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114)), לפיכך, חוקקה הוראת סעיף 71 לחוק הקובעת כך: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפא, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

36. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71 לחוק כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". בהקשר זה נאמר כי- "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש" (ראה אייזנשטיין, עמ' 223).

37. בהקשר זה נפסק זה מכבר כי תנאי לקיומה של הרחבה כהגדרת המונח בסעיף 71 לחוק הוא כי הצמדת החלק המסוים ברכוש המשותף צריך להיות בסמיכות פיסית לדירה המקורית (ע"א 1462/10 דוד עטיה נ' ליאור שגיא, פורסם ב"נבו", 2.8.12- להלן: "פרשת עטיה"). ככל שאין מדובר בהצמדה מסוג זה, אלא בבניית יחידות/ דיור נפרדות/ לא חל החריג הקבוע בסעיף 71 שעניינו ב"הרחבת דירה" ולפיכך נותר הכלל המעוגן בסעיף 62 לחוק המקרקעין ולפיו נדרשת לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות. אמנם, פתרון לצפיפות המגורים ניתן למצוא גם בתוספת בניה שאיננה סמוכה פיסית לדירה כגון בנית מחסן (כפי שנדון בפרשת עטיה) או בניית יחידת דיור נפרדת. אלא שבית המשפט העליון בפרשת עטיה מצא כי מלאכת האיזונים מצדיקה למצמצם את ההכרה בחריג ולא לראות ב"הרחבת דירה" ככוללת גם בניה ברכוש המשותף שאינה סמוכה פיסית לדירה. בהקשר זה יפים דבריו של כב' השופט פוגלמן בפרשת עטיה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"...אכן, ההתמודדות עם צפיפות הדיור היא תכלית חברתית חשובה, למען שיפור איכות החיים של רבים, ועל פני הדברים, אין לשלול את הטענה שבניית מחסן- אפילו זה אינו בסמיכות פיסיית לדירה- מאפשרת לפנות ממנה מיטלטלין ובכך להקל על הצפיפות בדירה. ברם, הדרישה לסמיכות פיסיית בין הבנייה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף..."

38. הוסיף השופט עמית בפרשת עטייה בהקשר זה כי- "

" הרחבת דירה משמעה בנייה, וכידוע, בנייה והצמדה אינם היינו הך. כך לדוגמה, יכול וגם הבניין יהיה צמוד לדירה בקומה העליונה, אך אין משמעות הדבר כי הבעלים של הדירה זכאי לבנות על הגג. לצורך הצמדת הדירה בקומה העליונה, נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות (סעיף 62 (א) סיפא) וכך גם לצורך בנייה על הגג. קבלת טענת המבקשים משמעה כי הלכה למעשה, ניתן יהיה להכשיר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף בבניין- אם בחצר ואם בגג ואם בחניון או החנייה בבניין- ברוב של 3/4, בטענה כי הבנייה מהווה הרחבה של הדירה. בכך נמצאת הופך את החריג לכלל, ומאפשר לבעלים של הדירה בקומת הקרקע לבנות מחסן על הגג המהווה רכוש משותף, מבלי להידרש להסכמת כל בעלי הדירות. תוצאה זו נוגדת את כוונת המחוקק והיא עלולה לרוקן מתוכן את הכלל לפיו נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לבניה על הרכוש המשותף."

39. במסגרת בחינת רף ההסכמות הנדרש על מנת לאפשר לבעל דירה להרחיב את דירתו, קבע המחוקק, בסעיף 71(ב)(ג) לחוק כי - **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**. היינו, מי שבנה "הרחבה דומה" יראה כמסכים להרחבה המבוקשת וזאת אף אם לא נתן הסכמתו הפוזיטיבית לאותה הרחבה. פרשנות המושג **"הרחבה דומה"** משמעה – הרחבה מסוג דומה; הרחבה שנועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי (ראה ע"א (מחוזי י-ס) 3235/02 **אביב דוד נ' גדולטר-בכבוד רונית** [פורסם בנבו], 2.3.03, אייזנשטיין, עמ' 234, ע"א (מחוזי חיפה) 22123-10-10 **זינגר ואח' נ' חדד ואח'**, [פורסם ב"נבו"], 14.3.11).

40. בע"א (חי) 2821/01 **ויליסקר נ' לויט** [פורסם ב"נבו"], 8.8.02 (להלן: **"עניין ויליסקר"**) נקבע כי לא רק בנייתה של הרחבה בפועל ניתן לראות כהסכמה מכללא, אלא גם מקרה בו בעל דירה הגיש בקשה לקבלת היתר בניה להרחבת דירתו וזו אושרה מבחינה תכנונית ואף ניתנה לה הסכמת רוב בעלי הדירות. בהקשר זה נפסק עוד כי גם אם בעל הדירה הגיש בקשה לבניית יחידת דיור נפרדת ולא להרחבה בלבד, יהיה צורך לשם אישור הבקשה בהסכמת כל בעלי הדירות ועל כן אין להסתמך במקרה כזה על הסכמה קונסטרוקטיבית מכוח סעיף 71 לחוק המקרקעין (ראה בסעיף 15 לפסק דינה של כב' השופטת וסרקרוג).

זכויות בנייה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. לא אחת נקבע כי המונח "זכות בנייה" או "אחוזי בנייה" משמעו "אפשרות ניצול הקרקע לבנייה על-פי הדין" (רע"א 2821/95 **לוסטיג נ' מייזלס**, פ"ד נ(1) 517, 527 (1996); ע"א 7394/03 **נכסי ר.א.ר.ד. חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, רחובות**, [פורסם בנבו] 6.12.06). זכויות בנייה אינן מהוות חלק מהרכוש המשותף (ע"א 136/63 **לוינהיים נ' שורצמן**, פ"ד יז 1726, 1723 (1963)- להלן: "**עניין לוינהיים**"), ע"א 432/83 **מזרחי נ' חביב**, פ"ד מ(4) 673, 680 (1986), ע"א 19/81 **ביבי נ' הוברט**, פ"ד לו (2) 497, 501 (להלן: "**עניין ביבי**"). עם זאת נקבע כי מדובר בנכס כלכלי בעל ערך המצוי בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות (ראה עניין ביבי, ע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון**, תק- על 2009 (3), 3111).

42. לפיכך נפסק, כי הצמדה של גג לבעל דירה מסוימת אינה מקנה לו גם את העברת אחוזי הבנייה לצורך בנייה על הגג המוצמד. בהקשר זה נקבע בע"א 239/79 **ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם** [פורסם בנבו] 2.3.80 (להלן: "**עניין גלבורט**") כי "יש לאבחן בין ההצמדה של חלק מן הרכוש המשותף לדירה מסוימת לבין הרשות לבנות. גם אם יש הסכמה להצמדה, אין פירושו עדיין כי יש בכך משום הסכמה של יתר בעלי הדירות לבנייה ודרושה בכל מקרה הסכמתם...". בע"א 749/76 **נחום וצביה יוסף ו-9 אח' נ' יצחק בכר**, פ"ד לב (3) 617 (להלן: "**עניין יוסף**") צוין בהקשר זה כך- "אין ספק שעצם הצמדת הגג ליחידה מסוימת אינה נותנת לבעל היחידה זכות לבנות על הגג כעולה על רוחו ללא הסכמת בעלי הדירות האחרות בבית, אלא גורמת אך ורק לכך שאותו חלק מהגג חדל להיות חלק מהרכוש המשותף והופך להיות חלק מהדירה". כך נקבע גם כי: "יש להבחין בין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף לאחת מן הדירות בבית המשותף, לבין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד. הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע, שלבעל הדירה קמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות הבנייה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות" (דברי השופט מצא (כתוארו אז) בע"א 7156/96 **שואעי נ' בכרך** [פורסם ב"נבו"] 9.2.99).

43. עוד נפסק, כי זכויות הבניה, בהיותן נכס בעל ערך כלכלי, יכולות להיות מושא להסכמות בנוגע לאופן חלוקתן. ניתן ללמוד על הסכמות כאמור מהוראות התקנון המוסכם המחייב את כל בעלי הדירות או מכל חוזה אחר הנכרת ביניהם. מכל מקום, השאלה האם הוקנו זכויות בנייה **מסוימות** למי מבעלי הדירות היא שאלה עובדתית הטעונה הוכחה (עניין לוינהיים, עניין ביבי).

44. היות שזכויות הבניה הן זכויות בבעלות משותפת, במקרים מסוימים, עת היו חלוקים ביניהם בעלי הזכויות על אופן חלוקת זכויות הבניה, ננקטו הליכים של פירוק שיתוף בזכויות הבניה (ראה למשל: ת"א (מחוזי י-ם) 3014/01 **אזולאי נ' אילוז** [פורסם ב"נבו"] 14.4.02, ת.א 3348/01 (מחוזי י-ם), **טובול נ' גרינברג**, [פורסם ב"נבו"] 30.12.05, ת.א (שלום הרצליה) 20431-02-10 **אור נ' יערי** [פורסם ב"נבו"], 31.12.17).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

45. ודוק. לא בכדי נדרשת הסכמת בעלי הדירות לא רק לשם הצמדת רכוש משותף לדירה פלונית אלא גם לשם ניצול זכויות הבניה ובניה על גבי שטח ההצמדה, שכן בניה, קל וחומר על גבי גג משותף, עשויה לשנות את מראה הרכוש המשותף ולהשפיע על הדירות כולן. בהקשר זה יפים גם דברים שנאמרו בעש"א (מחוזי חי') 36004-06-12 **פלאוט נ' הוד** (פורסם בנבו, 7.6.2013) - **"כל בניה ברכוש המשותף, של חלק מבעלי הדירות או של כל בעלי הדירות, עלולה לפגוע בזכויות הקניין של האחרים - במראה הבית, בצמצום השטח הפתוח, בפגיעה בגינה, בפגיעה באור ובאוויר וכיוצא'". כך שלא ניתן לומר, שאין לבעלי הרכוש המשותף, שאינם בעלי הרכוש המשותף הספציפי, כל נגיעה לבניה על השטח המשותף הספציפי"**.

46. לאור האמור לעיל נבחן להלן את נסיבות המקרה שלפנינו. ראשית יש להדגיש כי התובעת חזרה והבהירה, במספר הזדמנויות, כי איננה מתנגדת לבנית הרחבות לפי התכנית הישנה והחדשה וממילא התנגדותה נסבה רק על בניית יחידות חדשות ולא להרחבה לדירות קיימות (ראה דברי ב"כ, עו"ד ריזה, בדיון המקדמי מיום 15.5.17 ובסיכומים – פרוט' 29.6.20, עמ' 11 שורות 47-49, דברי המצהיר מטעמה, בנה, יצחק נפחא בחקירתו - פרוט' 10.9.19 עמ' 7 שורה 38, עמ' 8 שורות 19, 22, 48, דברי המצהיר בנה יהודה נפחא בחקירתו - עמ' 13 שורות 9-12, 16-17). לפיכך, עיקר הדיון יוקדש לשאלת אפשרותם של הנתבעים לבנות יחידה/ות נפרדת/ות על גבי הגג המשותף, בהתאם לתכנית החדשה.

הטענה לחלוקת זכויות הבעלות בגג המשותף בין העמודות

47. טענה עיקרית שהעלו הנתבעים 1-2 בהליך היא כי נעשתה חלוקה קניינית של הגג המשותף בין העמודות השונות באופן בה כל עמודה קיבלה בעלות על הגג ואת זכויות הבניה על גבי באופן נפרד. משכך, לטענתם, אין התובעת זכאית להתנגד לבניה על גבי הגגות שאינם מעל העמודה שלה ועליהם מיועדת להתבצע הבניה בהתאם לתכנית החדשה. זאת, לטענתם, משום שאין לה בהם כל זכות קניינית או חלק כלשהו מזכויות הבניה. בהקשר זה הפנו הנתבעים להסכם, עליו, לטענתם, חתמו בעלי הדירות להן צמוד הגג המשותף (דירות 5-12), למעט התובעת, לפני למעלה מעשור (הטענה הועלתה בשנת 2018 כך שהכוונה לחתימה בסביבות שנת 2008 ואולי אף קודם לכן). על פי הטענה, בעלי 5 דירות חתמו באופן אישי ובעלי 2 דירות נוספות מכרו זכויותיהם בגג לאולבסקי, כך שאולבסקי נכנס בנעליהם. לתמיכה בטענה זו צרף ורצברגר לתצהירו (נספח א') נוסח של הסכמה שאיננה חתומה ואף לא מצוינים בה בעלי הדירות אשר חתמו על פי הטענה, שלהלן יפורט נוסחו. הנתבעים טענו כי ההסכם/ההסכמים לא הוגשו בהליך חתומים על ידי בעלי הדירות הרלוונטיים כיוון שלאחר חתימתם הועברו לידי הרב משה בונים קראוס (להלן: **"קראוס"**), על מנת שישמור עליהם, אולם אלו אבדו ולא עלה בידי קראוס לאתרם (ראה תצהיר ורצברגר מיום 11.1.18, פסקה 4, תצהיר אולבסקי מיום 15.1.18, פסקה 5).

48. נוסח ההסכמה הנטענת כאמור, הוא זה (ראה נספח א' לתצהיר ורצברגר מיום 11.1.18 - להלן: **"הסכם העמודות"**):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

" אני הח"מ 1. נושא ת.ז.

2. נושא ת.ז.

על מנת למנוע סכסוכים ו/או מריבות ו/או אי הבנות בין השכנים וכדי לשמור על זכויותיהם של כל שכן ושכן בגג הבניין, הרי אנו מאשרים בזה כדלהלן:

1. אנו אחד הבעלים הרשום בבניין הנמצא ברח' אלקנה 23 ירושלים המחזיק בפועל של חלק יחסי בבעלות ו/או בזכויות למיניהן בגג הבניין זה השווה לשטח הדירה שלי והנמצא מעל לדירה שלי.

2. אני מסכים הסכמה סופית ומפורשת לוותר ויתור סופי ומוחלט על חלקי היחסי בשטח הגג הנמצא בשטח הגג הנמצא מעל לדירה של: 1. 2.

והשווה לחלוטין לחלקם היחסי בשטח הגג שמעל לדירתי והכל בתמורה לקבלת חלקם היחסי השווה של הצד השני בזכויות ו/או בבעלות בגג הבניין שמעל לדירתי.

3. מסמך זה הנו נוגע אך ורק לגבי הזכויות בשטחי הגגות של הבניין ואין ולא תהיה לו כל המשמעות ו/או נפקות לגבי זכויות הדיירים בדירותיהם ו/או ביתר חלקי הבניין".

49. בנוסף להסכם העמודות, צירפו הנתבעים לראיותיהם (נספח א' לתצהיר אולבסקי מיום 15.1.18) הסכם

מיום 10.11.15 שנערך בין הנתבע 1 למר בנימין אלטר (להלן: "אלטר"), שהוא חתנו של אולבסקי, במסגרתו

מתואר ורצברגר (המוגדר בהסכם כ-"מוכרים") באופן הבא:

"הואיל המוכרים הנם הבעלים, במשותף עם הבעלים הרשומים של הדירות הידועות כתתי חלקות 5-12, של גג הבניין בשטח של כ-264 מ"ר, המוצמד לפי נסח הרישום בהצמדה משותפת לת"ח 5-12, והמסומן בתשריט הבית המשותף כגג (להלן: "הגג") ושל חלק יחסי, לפי שיעור חלקם של המוכרים ברכוש המשותף מתוך סך כלל שטחי הרכוש המשותף, של זכויות הבנייה הקיימות ושתהיינה קיימות בעתיד, מכל מין וסוג, הניתנות ושהיו ניתנות לניצול בשטח החלקה כתוצאה מכל תכנית שחלה ושתחול על הבניין (להלן: "זכויות הבנייה ו/או אחוזי הבנייה") הכל כמפורט בנסח המצ"ב כנספח א' ובצו רישום הבית המשותף ותשריט הבית המשותף המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו המסומנים נספח ב'...

והואיל וברצון המוכרים למכור את מלוא זכויותיהם בגג ואת מלוא חלקם בזכויות הבניה ואחוזי הבניה כהגדרתם לעיל (להלן: "הממכר") לקונה, והקונה מעוניין לרכוש את מלוא הזכויות בממכר...."

(להלן יכונה הסכם זה-"הסכם אלטר")

50. יש לדון אפוא בשאלת תוקפו המשפטי של "הסכם העמודות" והאם הוא אכן מלמד על חלוקה קניינית

של הגג וזכויות הבניה בו לעמודות השונות. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי שאין מדובר

בהסכם בעל תוקף משפטי אשר ניתן להסיק ממנו את שמבקשים הנתבעים.

51. בראש ובראשונה הנתבעים כלל לא הוכיחו כי הסכם העמודות אכן נחתם ואושר על ידי בעלי הדירות

אליהם הוצמד הגג המשותף כנדרש. היות שהגג הוא הצמדה משותפת ל-8 דירות, הרי שהיה צורך

להראות שכל בעלי הדירות אליהן צמוד הגג היו צד ואישרו הסכמה זו. אולבסקי טען בתצהירו כי

חתמו עליו בעליהם דאז- של תתי חלקות 6 (קרמר), ת"ח 12 (צדיק), ת"ח 5 (פרקל) ות"ח 8 (רוזנברג).

אולבסקי אישר כי התובעת ובעלי ת"ח 7 דאז טרזי לא הגיעו למעמד החתימה (ראה פסקה 5 לתצהיר

אולבסקי מיום 15.1.18, עמ' 19 שורה 47-25). דהיינו ממילא חסרות הסכמות של בעלי דירות אליהם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צמוד הגג על מנת לראות בהסכם העמודות כהסכם שיש בו כדי למכור חלקים בגג המשותף, השייכים לכלל בעלי דירות אלו.

52. יתרה מכך. הנתבעים אף לא הוכיחו כי הסכם העמודות נחתם ולו על ידי חלק מבעלי הדירות אליהן צמוד הגג. ראשית, אף לטענת אולבסקי חתמו על ההסכם לכל היותר 5/8 בעלי דירות אליהן צמוד הגג המשותף (ראה סעיף 5 לתצהירו מיום 15.1.18). שנית, ההסכם החתום כלל לא הוגש בהליך אלא "טיוטה ריקה" שלו בלבד, נעדרת שמות או תאריך. הסברי הנתבעים לאי הגשת עותקי החתומים היו כי אלו נשמרו בידי קראוס אולם אבדו לו. בעלי הדירות החותמים כמו גם קראוס לא זומנו לעדות בהקשר לטענה זו וזאת מבלי שהנתבעים סיפקו כל הסבר לאי זימונם. די בכך בכדי לפגוע באופן משמעותי בטענה בדבר קיומו של ההסכם. יוזכרו הדברים הידועים שנאמרו בפסיקה אודות הימנעות מהבאת עדים, ובין השאר, על ידי כב' השופטת בן עתו (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה (1) 736 (1980), בעמ' 760, מול האותיות ה-ו): "... כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים וככל שהראיה יותר משמעותית כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות יותר מכריעות ויותר קיצוניות נגד מי שנמנע מהצגתה". בעניין זה ראה גם: ע"א 635/89 אנקונה נ' גוטמן תק-על 90 (3) 705 (1990); ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון פ"ד מט (1) 450 (1995); יעקב קדמי על הראיות - הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650.

53. יתרה מכך. הסכם העמודות אינו עולה בקנה אחד עם הסכם אלטר, המאוחר לו. לו אכן היה נחתם הסכם העמודות ובעלי הדירות היו רואים בו כהסכם שיש בו כדי להעביר בעלות קנייניות בגג ובזכויות הבניה באופן שהגג מעל כל עמודה מוצמד רק אליה, לרבות זכויות הבניה, הרי שיש להניח כי הדבר היה עולה במפורש גם בהסכם אלטר. אולם, על אף שורצברגר העיד כי אולבסקי הוא שעמד מאחורי ניסוח הסכם אלטר (ראה פרוט' 10.9.19 עמ' 15 שורות 8-9) וצבי קרמר העיד כי חתם על ההסכם העמודות לאחר שמכר לאולבסקי את דירתו, היינו בעת שאולבסקי היה בתמונה (ראה סעיף 6 לתצהירו), בחר אולבסקי שלא להזכיר כלל את הסכם העמודות או תוצאותיו המשתמעות בהסכם אלטר. בעוד שהסכם העמודות עוסק לכאורה בחלוקה קניינית של הגג וזכויות הבניה בו, עוסק הסכם אלטר במכירת של זכויות בניה כשורצברגר אינו מוגדר שם כבעל הגג שמעל דירתו לרבות זכויות הבניה בו (למצער עם יתר בעלי הדירות בעמודה אליו משתייכת דירתו) אלא כ-264 מ"ר, המוצמד לפי הרשומים של הדירות הידועות כתתי חלקות 5-12, של גג הבניין בשטח של כ-264 מ"ר, המוצמד לפי נסח הרישום בהצמדה משותפת לת"ח 5-12, והמסומן בתשריט הבית המשותף כגג (להלן: "הגג") ושל חלק יחסי, לפי שיעור חלקם של המוכרים ברכוש המשותף מתוך סך כלל שטחי הרכוש המשותף, של זכויות הבניה הקיימות ושתהיינה קיימות בעתיד..."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. אמנם, מטעם הנתבעים העידו שניים מבעלי דירות דאז או נציגיהם בנוגע לחתימה על הסכם העמודות-מר דוד צבי קרמר ומר דני צדיק, אולם עדויותיהם היו חסרות ולא עלה מהן, ברמת הוודאות הנדרשת להוכחה, כי הסכם העמודות אכן נחתם על ידי כל בעלי הדירות שנטען כי חתמו עליו. דוד צבי קרמר, מי שהיה בעלי ת"ח 6, אמנם העיד על חתימה על הסכם העמודות לכאורה, אולם טען כי הוא מתייחס ל"חלוקת שימוש" (ראה סעיף 4 לתצהירו מיום 11.1.18) ומכל מקום לא ידע להעיד לגבי זהות החותמים על ההסכם ומי מבעלי הדירות אכן היה שותף לחתימה עליו (ראה פרוט' מיום 27.5.20, עמ' 2 שורות 18-19). מר דני צדיק, אשר אביו היה בעל ת"ח 12, העיד גם הוא על חתימת הסכם העמודות וטען כי חתם בזמנו בשם אביו, בעת שאביו היה בעל הדירה. צדיק העיד כי רק בעלי הדירות בקומה השנייה והשלישית היו שותפים לחתימת הסכם העמודות (ראה פרוט' מיום 27.5.20 בעמ' 5 שורות 16-19). עם זאת, גם צדיק לא ידע להעיד אילו מבין בעלי הדירות להן צמוד הגג בצמידות משותפת היו מבין אלה שחתמו על ההסכם (עמ' 5 שורה 25). ממילא, לא הוכח כי אף צדיק קיבל ייפוי כוח כדין מאביו לחתום בשמו על הסכם העמודות.

55. בחקירתו, לא ידע ורצברגר להסביר מי מבעלי הדירות נרשם בראש הסכם העמודות ומי בהמשכו, היינו מי ויתר למי על זכויותיו על פי הנטען (ראה פרוט' מיום 10.9.19 עמ' 15 שורה 50, עמ' 16 שורה 1). כך גם ורצברגר ואולבסקי לא סיפקו הסבר מספק לשאלות מדוע לא טען ורצברגר על דבר קיומו של הסכם העמודות בוועדה לתכנון ובניה כמענה לטענת התובעת כי מדובר בגג משותף (ראה שם בעמ' 15, עמ' 19 שורות 17-25) ומדוע לא נשמר עותק אצל ורצברגר. ורצברגר אף לא זכר מי היו בעלי הדירות אשר חתמו לטענתו על הסכם העמודות. אי מתן תשובות סדורות לשאלות בסיסיות אלו מעלה גם הוא כשלעצמו ספק רב בטענה בדבר חתימת ההסכם על ידי בעלי הדירות הנטענים.

56. יתרה מכך. גם לו היה מוכח כי בעלי הדירות הרלוונטיים חתמו על הסכם העמודות (ולא כך הוא) עדיין לא היה מקום לראותו כהסכם תקף ומחייב המלמד על חלוקה קניינית ולמעשה הצמדה של הגג המשותף וזכויות הבניה בו לכל עמודה ועמודה. הסכם העמודות עוסק בביכול במכירת "חלק יחסי בגג" שמעל הדירות האחרות תמורת רכישת "חלק יחסי בגג" שמעל דירת הרוכש. אולם, למוכר, כמו גם לרוכש (בהנחה ששניהם בעלי דירות להם מוצמד הגג המשותף), אין כל חלק מסוים בגג כי אם חלק יחסי בו בלבד. במצב דברים זה לא ניתן למכור חלק מסוים בגג שמעל דירה אחת תמורת חלק מסוים בגג שממוקם מעל לדירה אחרת. אמנם, ההסכם נוקט בלשון "חלק יחסי" אולם כוונת הצדדים היא, על פי הנטען, למכור חלקים בגג שמעל דירת X תמורת חלקים בגג שמעל דירת Y, כאשר הדבר בלתי אפשרי עת לבעלי הדירות חלקים יחסיים ובלתי מסוימים בגג המשותף. כך למשל, אין רשאי בעל דירה למכור את חלקו היחסי במחסן תמורת חלק יחסי של בעל דירה אחר בחצר ובכך בביכול לרכוש חלקים מסוימים ברכוש המשותף, בהעדר הצמדה כדין. כלל זה עולה ישירות מהוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין הקובעת כי: " (א) לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף (ב) עיסקה בדירה תחול גם על החלק ברכוש המשותף הצמוד אליה, ואין תוקף לעסקה ברכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף בנפרד מן הדירה; אין בהוראה זו כדי למנוע פעולה הבאה להקטין או להגדיל את שטח הקרקע שבכרש המשותף.

57. זאת ועוד. ההסכם גם נעדר מסוימות וחסר בפרטים מהותיים. מעבר לעובדה כי בהסכם העמודות לא מצוין כנדרש זיהוי המקרקעין ואף נעדר ממנו תשריט, הרי שלא מובהר מהו אותו "שטח הגג שמעל הדירה" עליו מוותר כביכול המוכר, מהם גבולותיו וכיוצא ב.

58. אם לא די בכך, הרי שהסכם העמודות כולל בתוכו חלוקה של זכויות בניה בין בעלי הדירות וזאת בעוד שזכויות הבניה כלל אין שייכות לבעלי דירות הגג בלבד אלא לכל בעלי הדירות. הצמדה של גג, כעולה מהרקע המשפטי לעיל, אינה מקנה מאליה גם את הזכות לבנות בגג ואת אחוזי הבניה. היות שבמקרה דן אין כל הוראה בתקנון בנוגע לחלוקת זכויות הבניה הרי שאלו שייכות לכל בעלי הדירות גם יחד. לפיכך ממילא, בהיעדר חתימת 4 הדירות אליהן לא צמוד הגג, אך הן בעלות זכויות בניה בו, אין כל תוקף לחלוקת זכויות הבניה לקניינם של בעלי דירות בעמודה כזו או אחרת.

59. יש לציין עוד כי הסכם העמודות לא קיבל כל תוקף רישומי בתקנון והצו החלים על הבית המשותף, ואף לא נטען כי שולמו וממילא דווחו המיסים כנדרש מעסקת מכר כנטען. עניין זה תורם ממילא לספק הרב המתעורר ביחס לטענה בדבר קיומו.

60. לסיום פרק זה יש להוסיף ולציין כי הנתבעים עשו שימוש מעורב במונח "זכות שימוש בגג" ובמונח של "זכות בעלות או "זכות קניינית" בגג. העובדה כי לטענת הנתבעים הייתה קיימת זכות שימוש ייחודית בגג שמעל כל אחת מהעמודות לדירי אותה עמודה או דירת הגג שבאותה עמודה, גם אם נכונה היא (ואין צורך להכריע בכך), אין בה כדי ללמד על זכות בעלות בגג IN REM. לכל היותר, מדובר היה בזכות **שימוש** הדירה, שאיננה כוללת את זכויות הבניה והשימוש בהן. לא נטען וממילא לא הוכח כי מדובר בזכות שימוש שמי מבעלי הדירות הסתמך עליה ושניתנה בגינה תמורה באופן המצדיק לראותה כזכות שימוש בלתי הדירה.

61. מכל אותם טעמים אשר פורטו לעיל, עולה כי דבר קיומו של הסכם העמודות לא הוכח וככל שהיה מוכח כי נחתם- נמצא כי הוא חסר תוקף משפטי ואין בו כדי ללמד על חלוקה או הצמדה קניינית של חלקי הגג השונים בין ה"עמודות". לפיכך טענת הנתבעים כי לתובעת אין זכות קניינית בגג שמעל יתר הדירות בקומה השלישית או בזכויות הבניה ביחס לגגות אלו- להידחות.

רף ההסכמות המצוי בידי הנתבעים למימוש התכנית החדשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

62. למעשה מן הבחינה העובדתית אין מחלוקת כי בהתאם לתכנית החדשה עתידות להתווסף 5 יחידות דיור חדשות: ורצברגר עתיד לקבל יחידה נפרדת וחדשה המיועדת בפועל לאולבסקי בהתאם להסכמים בין ורצברגר לאלטר (בגג הקיים- המקום בו מקבלות יתר דירות הגג בקומה השלישית הרחבות לדירותיהן). בנוסף מאפשרת התכנית לבנות 4 יחידות דיור נוספות על גבי הגג החדש שיוצר לאחר בניית הקומה הרביעית, בקומה החמישית. לטענת אולבסקי, יחידות חדשות אלו מיועדות לבעלי הדירות בקומה השנייה (ראה עדות אולבסקי, עמ' 20 שורות 10-12).

63. להבנת התמונה המלאה יש לציין כי מי שעמד מאחורי התכנית החדשה והיה הרוח החיה בה הוא אולבסקי. ורצברגר צוין כמגיש התכנית היות שאולבסקי אינו בעל דירה בבית המשותף. ורצברגר נשאל בהקשר זה בחקירתו הנגדית: "בוא נדבר על התכנית שהגשת. התכנית החדשה. אם אני מבין נכון בקומה חמש... יש ארבע יחידות נפרדות... בקומה הרביעית... אמורות להיות לפי התכנית שלוש הרחבות..." ורצברגר השיב: "לא יודע. מה שהוא עשה עשה" (פרוט' 10.9.19, עמ' 16 שורות 9-6) ובהמשך- "ש. אתה מספר לי שבעצם אולבסקי עשה הכל" ת. אני סמכתי עליו, הוא נתן לי את שלי ואז אני מסכים" ש. אתה לא מעורב באדריכלים, מהנדסים, עמלות, אגרות, שכר טרחה"? ת. לא אני" (עמ' 16 שורות 23-24. ראה גם עדותו בעמ' 17 שורות 15-20). למעשה, אולבסקי הגיע להסכמות עם מרבית בעלי הדירות בנוגע לתכנית החדשה (ראה עדות אולבסקי, פרוט' 10.9.19 עמ' 20 שורות 30-41). במסגרת זו הוכח שהציע לפחות לחלק מבעלי הדירות מתן שירותי בניה, נשיאה בעלות בנית תוספות בניה וקבלת יחידות דיור תמורת קבלת הסכמתם לשימוש בגג המשותף ובניה בו ולניצול זכויות הבניה וייתכן שגם עבור תמורה נוספת. כך למשל העיד ורצברגר כי בתמורה למכירת חלקו בגג וזכויותיו בו " (אולבסקי) נתן לי את הבנייה... מטבח, מרפסת, ... עשה לי מטבח חדש...בלטות חדשות.... (ראה פרוט' מיום 10.9.19 עמ' 14 שורות 31-40). בדומה העידה גם ציפורה שכטר כי תמורת מכירת זכויותיה בגג נשא אולבסקי בכל עלויות בניית ההרחבה לדירתה (פרוט' 10.9.19, עמ' 24 שורות 32-37).

64. כפי שעלה מהאמור ברקע המשפטי לעיל, בנייתה של יחידה חדשה, קל וחומר מספר יחידות חדשות, מצריכה את הסכמת כל בעלי הדירות, שכן לא ניתן לראות בה "הרחבת דירה". בהקשר זה יש לדחות את טענות הנתבעים כי ניתן לראות את בניית היחידות הנפרדות כ"הרחבות דירה" על אף היעדר סמיכותן הפיסית. טענה זו כאמור כבר נדונה והוכרעה בפרשת עטייה ומהווה לפיכך הלכה מחייבת. יש לבחון עתה מהו רף ההסכמות הקיים בידי הנתבעים לשם בניית היחידות הנוספות, הנפרדות, בהתאם לתכנית החדשה (שכן כאמור אין התובעת מתנגדת לחלקה של התכנית המאפשר בתכנית הרחבת דירות קיימות).

65. התובעים הציגו את הסכמתם הפוזיטיבית של 11/12 בעלי דירות למימוש התכנית החדשה, היינו של כל בעלי הדירות למעט התובעת. הסכמת ורצברגר שניתנה מטבע הדברים בהיותו מגיש הבקשה וכן הסכמת 10/12 בעלי דירות נוספות. בעלי תתי חלקות 3,4,5,6,7,8,11,12 ניתנה בנוסח הבא (נספח ד' לתצהיר אולבסקי): " אנחנו הח"מ.... מאשרים בזאת את הסכמתנו לתוספות בנייה של שתי קומות על גג הבניין בהתאם לתב"ע 5613, לתב"ע 017221-101 (להלן- "התוכניות") והיתרי בנייה שיינתנו מכוח תכניות אלה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובכלל זה מסכימים לכל שימוש בשטח הגג הקיים ו/או הגג החדש לפי תב"ע 5613 ו/או בכל אחוזי הבנייה, הנדרשים לביצוע תוספות הבנייה לפי התוכניות". הסכמת בעלי דירות 1,2,3,4 ניתנה בנוסח זה: " ... נותנים את הסכמתנו להצמדת כל זכויותינו, ככל שקיימות, בגג החדש שיוותר כתוצאה מבניית קומה רביעית של הבניין על דרך מימוש תב"ע 5613 ו/או כתוצאה מבניית קומה חמישית על דרך מימוש לתב"ע 101-017221, לרבות זכויות הבניה (להלן - "הגגות והתוכנית") לדירות הרשומות כתתי חלקות 6,7,10,12 ו/או למי מדירות אלה ואנחנו מסכימים לשינוי ו/או תיקון מסמכי רישום הבית המשותף, כולל צו רישום ו/או תקנון ו/או תשריט בהתאם".

66. אמנם, למעט הסכמת בעלי תתי חלקות 1-4 אין בהסכמות שניתנו כדי ללמוד למי מבעלי הדירות תינתן הזכות הקניינית באותן דירות, אולם מכל מקום, הסכמת בעלי תתי חלקות אלו להוספת 5 יחידות דיור נפרדות וחדשות על גבי הגג הקיים וכן הגג החדש שייווצר - ניתנה. התובעת לא טענה כנגד תוקפן של ההסכמות שהוצגו ולא ביקשה לחקור את בעלי הדירות שנטען כי נתנו הסכמתם בהתאם ולפיכך יש לקבוע כי הסכמתם לבניה בהתאם לתכנית החדשה ובכלל זה הוספות 5 יחידות חדשות אכן ניתנה.

67. הנתבעים לא אומרים נואש. לטענתם, הנתבעת נתנה הסכמתה - בין אם במפורש באמצעות ילדיה ובין אם הסכמה קונסטרוקטיבית. לחלופין נטען כי יש בסמכות המפקחת להידרש לטעמי התנגדותה שכן יש בהם משום חוסר תום לב, ועל כן יש לקבוע כי ניתן לבצע את הבניה גם בהעדר הסכמתה המפורשת. דינן של טענות אלו להידחות. ראשית, ביחס להסכמה שנתנו כביכול ילדיה של התובעת למימוש התכנית - הרי שזו כלל לא הוכחה. הנתבעים טענו בעלמה כי בפגישה עם אולבסקי נתנו ילדיה את הסכמתם למימוש התכנית, וזאת כאשר ילדי התובעת הכחישו טענה זו. אמנם, ניתן להוכיח הסכמה גם בעל פה, אולם זו צריכה להיות מוכחת באופן ברור באמצעות ראיות מפורשות (ראה: בר"ע 815/81, **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו (3) 78). במקרה זה לא הובאו כל ראיות מלבד טענתו של אולבסקי שהייתה כללית ובלתי מבוססת. מכל מקום, אף אם היה ממש בטענה שילדי התובעת נתנו הסכמתם, הרי שהתובעת עצמה היא שצריכה להסכים למימוש התכנית החדשה ואין לילדיה כל מעמד להסכים בשמה. הסכמת התובעת, אף לשיטת הנתבעים, לא ניתנה.

68. ביחס לטענה בדבר קיומה של הסכמה קונסטרוקטיבית. טענה זו רלוונטית, כאמור בסעיף 71 לחוק, כאשר עסקינן במי שהרחיב דירתו המוחזק כמסכים ל-"הרחבת דירה" דומה, או למי שהגיש היתר בניה, בקשתו אושרה ויש בידיו הסכמת רוב בעלי הדירות כפי שנקבע בעניין ויליסקר. במקרה הנדון התנגדות התובעת איננה להרחבה אלא לבניית יחידות נפרדות וממילא מונח זה אינו רלוונטי לענייננו. לא למותר לציין כי אף אם הייתה הסכמה מסוג זה תקפה גם ביחס למקרה בו נבנות יחידות נפרדות ולא להרחבה בלבד, לא היה בכך כדי להועיל לנתבעים. לכל היותר ייתכן שניתן היה לראות בתובעת ככזו שמסכימה קונסטרוקטיבית להרחבה דומה לזו המתאפשרת לה מכוח התכנית החדשה (ביחס אליה הודיעה פוזיטיבית כי היא מסכימה וממילא אין צורך בהסכמה קונסטרוקטיבית), אולם לא לבניית יחידות או יחידות דיור נפרדות. טענת הנתבעים 1-2 כי מכוח עניין ויליסקר ניתן לראות גם יחידת דיור נפרדת כהסכמה להרחבה דומה, מערבת מין בשאינו מינו. גם אם ניתן היה לראות בבניית יחידת דיור בנסיבות מסוימות כ"הסכמה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קונסטרוקטיבית" היה זה, בדומה לנסיבות עניין ויליסקר, כאשר מי שמתנגד להרחבה בנה בעצמו יחידת דיור נפרדת, ועל כן הסכמתו היא מגדר "קל וחומר". לא כך במקרה שבנדון בו התובעת כלל לא בנתה או ביקשה היתר בניה לבניית יחידת דיור נפרדת עבורה.

69. הטענה כי התובעת אף לא התנגדה להרחבה שביצעה תת חלקה 12 ואף לא בדקה אם תת חלקה 12 פוצלה לאחר ההרחבה, אין בה רבותא. כלל לא נטען במפורש או הוכח שתת חלקה 12 פיצלה את דירתה והיעדר "בדיקה" מטעם התובעת בהקשר זה אין בו כדי לפגום בתום לבה. כך גם בטענה כי משך שנים מבקשת תת חלקה 12 היתר בניה לבנית קומה חמישית נטענה בעלמה מבלי שהובאו לכך ראיות כלשהן.

70. באשר לטענה החלופית בדבר התערבות בטעמי ההתנגדות. הפסיקה אשר דנה בבחינת "התנהגות הצדדים" במובן של עמידה על טעמי המתנגדים לבניה המבוקשת (אם תרצה- טעמי ההתנגדות לפגיעה כזו או אחרת בזכות הקניינית, במובן של קיום בתום לב), אמנם הכירה בסמכות הערכאות השיפוטיות להביא בגדר מכלול שיקוליהם גם את הסיבה הנעוצה בהתנגדות, אולם הדגישה כי רק התנגדות בלתי הוגנת, הנעוצה בקינטור או סיבות הנוגדות את שיטת המשפט, תהא כזו אשר נכון יהיה להתעלם ממנה ולא להביאה במסגרת מניין ההתנגדויות לבניה המבוקשת ברכוש המשותף. יתרה מכך, סמכות זו הוכרה רק בעת שמדובר בהסכמה להרחבה דירה ולא לבנית יחידה נפרדת. אמנם, בעניין נטלה (ע"א (חי) 835/08, **נטלה צבי נ' עטרה פרי** [פורסם ב"נבו"] 18.11.09, להלן: "**עניין נטלה**"), נקבע כי בסמכות המפקחת לבחון את טעמי ההתנגדות "**גם אם הבדיקה הנדרשת תיעשה בזהירות ותבחן אם אכן מדובר בהתנגדות סתמית, שאינה עניינית**" אולם בעניין **גורי** (עש"א (חי) 17181-05-11, **גורי אברהם נ' יאיר פדאל**, [פורסם ב"נבו"], 20.9.11), הובהרה סמכות המפקחת להידרש לטעמי התנגדות עת נקבע כי אמנם אין לאפשר התנגדות ללא הנמקה, אולם "**בשלב שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של בית המשפט לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר**". כך למשל, נקבע כי ניתן להתערב בנימוקי ההתנגדות עת למשל "**בעלים של מס' דירות מתנגדים מתוך כוונת קינטור או נסיבות הנוגדות את שיטת המשפט**". (ראה בהקשר זה גם: עש"א (מחוזי חיפה) 13877-07-09, **אילן קסרי נ' שאחב שלומוב**, [פורסם ב"נבו"], 16.8.10).

71. בעניינינו, לא התרשמתי כי התובעת מתנגדת מתוך כוונת קינטור או טעמים הנוגדים את שיטת המשפט וכי יש בהתנגדותה משום חוסר תום לב. התובעת, לה זכויות קנייניות בגג המשותף וזכויות משותפות בזכויות הבניה, מבקשת שלא יעשה בהן שימוש לצורך בנית יחידות דיור חדשות, ובכך מבקשת להגן על זכויותיה הקנייניות. לא מצאתי כי מדובר בטעמים שאינם סבירים. ברי כי לזכויותיה ערך כלכלי והיות שהצדדים לא הגיעו לעמק השווה ביחס לתמורה שתקבל התובעת, היא רשאית להתנגד לבניה תוך הגנה על זכויותיה אלו. במצב דברים זה, סמכות המפקחת לבחון בדקדוק את כל טעמי ההתנגדות של התובעת אשר פורטו בטענותיה ממילא מוגבלת ומצומצמת לא מצאתי צורך להידרש לבחינתן.

72. יוצא אפוא כי בידי הנתבעים הסכמותיהם של כלל בעלי הדירות, למעט התובעת. אמנם מדובר ברוב גדול ומשמעותי, אולם, לשם בניית יחידות דיור חדשות נדרשת הסכמת כל (100%) בעלי הדירות כאמור. משלא ניתנה הסכמתה של התובעת ושעה שנקבע שאין מדובר ב"הרחבת דירה" ביחס אליה ניתן להסתפק ברוב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של 3/4 מבעלי הדירות בלבד, הרי שאין אלא לקבוע כי אין בידי הנתבעים את הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש על מנת לבצע את בניית יחידות הדיור החדשות מכוח התכנית החדשה.

73. לפיכך אני מורה כי נאסר על הנתבעים 1-2 או מי מטעמם לבנות יחידות דיור נפרדות לפי התכנית החדשה, או בכלל, מבלי שיש בידם את הסכמת כל בעלי הדירות (100%).

74. באשר לסעד ההריסה. בביקור שערכתי במקום נוכחתי לראות, כאמור, כי על גג הבניין נבנתה יחידה נפרדת. בשלב הביקור ניתן היה להבחין בקירות ובקונטור, יחידה זו עדיין לא הייתה מחוברת לתשתיות או מרוצפת/ מסוידת. טענת אולבסקי כי נאלץ לבנות אותה בשל בעיות רטיבות, מטעמי יציבות קונסטרוקציה או המראה האסתטי של הבניין אינה משכנעת, בלשון המעטה. בבעיות רטיבות יש לטפל באמצעות ביצוע איטום ראוי על ידי אנשי מקצוע. בניית יחידת דיור על גבי הגג אינה סוג הטיפול המתאים לבעיות מסוג זה. יתרה מכך, הנתבעים לא הציגו כל חוות דעת מומחה המלמדת כי אכן הייתה רטיבות אשר הצריכה טיפול כלשהו. גם טיפול ביציבות או במראה הבניין אינו דורש בניית יחידת דיור נפרדת על הגג. אם לא די בכל הרי שטענת אולבסקי בתצהירו, בהתייחס לפעולות יציקת הקירות וסגירתם, לפיה "כל הפעולות נעשו בתיאום עם העירייה, וזאת במסגרת הליכי הוצאת היתר בניה בתיק 879.03/2016 " (סעיף 5 לתצהירו המשלים מיום 24.10.18) התבררו כבלתי נכונות שעה שהוא עצמו הודה בחקירתו כי **"עם מהנדס שלי, המילה עירייה זה טעות"** (עמ' 21 שורה 43).

75. בהקשר זה יש להוסיף כי הגם שמדובר בסעד חמור באופיו, קיימים שיקולים עיקריים המנחים את בית המשפט בבואו להכריע בסעד מסוג זה. עמד על כך כב' השופט טירקל ברע"א 6339/97, **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה (1) 199 (להלן: **"פרשת רוקר"**) - עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה, עוצמתה של הפגיעה בזכות לרבות היקף ומשך הפגיעה, שיקול שלישי המשני בחשיבותו לקודמיו הוא עוצמת התוצאות של הריסת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות ושיקול רביעי שהוא התנהגותם של בעלי הדין. בפרשת רוקר נקבע, בכל הנוגע לשיקול הנעוץ בהתנהלותם של בעלי הדין כי- **"לא הרי מסיג גבול בתום לב כמסיג גבול במצח נחושה"** (וייסמן בספרו הנ"ל, דיני קניין- בעלות ושיתוף [68], בעמ' 63). **המערערים עשו מעשיהם בעזות מצח ובכך העידו על עצמם שהם מקבלים עליהם את תוצאות הריסת המבנה והחזרת המצב לקדמותו. ההוצאות שיהיה עליהם לשאת בהן כדי להסיר את רוע מעלליהם אינן יכולות לשמש שיקול לטובתם"** (שם, בפסקה 19 לפסק דינו של השופט טירקל).

76. במקרה הנדון עסקינן בבניית יחידה נפרדת אשר התבצעה בעיצומו של ההליך המשפטי, כאשר זכותם של הנתבעים לבצע את הבניה האמורה נתונה במהלכו של בירור. מדובר בבניה שבוצעה באופן בוטה, בניסיון להעמיד את התובעת בפני עובדה מוגמרת. היקף ומשך הפגיעה כמו גם התנהלות הנתבעים גוברת במקרה זה על תוצאות הכלכליות הכרוכות בהריסת הבנייה. מדובר, כאמור ביחידה אשר נבנתה ללא הסכמת כל בעלי הדירות ואף מבלי שניתן לה היתר בניה. במצב דברים זה יש לקבל את הסעד המבוקש ולהורות על הריסת היחידה הנפרדת אשר נבנתה על גג הבית המשותף. **לפיכך אני מורה לנתבעים 1-2, ביחד ולחוד,**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להרוס בתוך 90 יום מהיום את היחידה אשר נבנתה בגג המשותף (בחלקה מעל דירת ורצברגר ובחלקה מעל דירת שכטר) ולהותיר את הגג פנוי בשטח בו נבנתה יחידה זו מכל חפץ.

שכטר

77. כנגד שכטר מופנות למעשה שתי טענות- האחת כי במסגרת היתר הבניה שקיבלו להרחבת דירתם, הרחיבו דירתם רק בחלק מהשטח שהותר להם לפי ההיתר, כאשר בשטח הנותר עשו יד אחת עם הנתבעים לשם בניית יחידה נפרדת, כאשר "צרפו בפועל חלק משטח דירתם המתוכננת לדירה הבנויה מעל דירתו של ורצברגר", השנייה ביחס להרחבת דירתם הקיימת- נטען כי פיצלו את הדירה המורחבת לשתי יחידות נפרדות. התובעת לא עתרה להריסת ההרחבה שביצעה שכטר, על אף טענתה כי נעשתה שלא בהתאם להיתר הבניה ולהסכמתה, אלא לסילוק יד מהגג המשותף " **בחלק שלגביו לא ניתן היתר בניה כלומר- מגבול דירת שכטר והלאה**" (ראה סעיף 8.2 לכתב התביעה המתוקן). כך גם התבקש: **"להשיב את הבניה שבוצעה בהרחבת משפחת שכטר ליעודה המקורי- הווה אומר- דירה מורחבת ללא פיצול"**. מכאן, שנותן לבחון האם אכן דירת שכטר פוצלה באופן המצדיק לראות בכך פגיעה בתובעת ומתן סעד כנגד שכטר.

78. מן הבחינה העובדתית אין חולק כי שכטר לא ניצלו את כל השטח בו התאפשר להם לבנות לפי היתר הבניה לצורך הרחבת דירתם ובחרו לבנות רק בחלק משטח זה כאשר בחלק נוסף של הגג אשר יועד להרחבת דירתם לפי היתר הבניה אפשרו לאולבסקי לבנות יחידה נפרדת. עם זאת, לא הוכח כי שכטר הם שבנו, על פני חלק הגג שנותר לבניית הרחבת דירתם, יחידה נפרדת שלא כדין או שזו עתידה לשמש אותם באופן כלשהו. אמנם, הוכח כי שכטר נתנו לכך יד תוך הגעה להסכמות עם אולבסקי כי האחרון יבנה עבורם את תוספת הבניה בתמורה להסכמתם לבניה שיחפוץ בה (ראה עדות אולבסקי, פרוט' מיום 10.9.19 עמ' 20 שורות 30-41, עדות ציפורה שכטר, עמ' 24 שורות 4-5, 32-37). אולם אין מדובר בבניה שביצעו שכטר או שהיא בשליטתם באופן המצדיק ליתן כנגדם סעד בהקשר לבניה שאינה חלק מהרחבת דירתם בפועל.

79. יש לדון עתה בטענה הנוספת בנוגע לפיצול דירת שכטר המורחבת. המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בעבירות על חוק התכנון והבניה, ולפיכך אין עסקינן בשאלה האם שכטר הפרו את תנאי היתר הבניה או סטו מההיתר. הדיון לפנינו נוגע לטענה בדבר "פגיעה" המבוססת על סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המורה כי **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת"**. ככלל, הפסיקה הכירה בכך שפיצול דירה מוריד את ערך הדירות בבית, שכן בתשתית הבית כולו, יהיה על בעלי הדירות המקוריים להתחלק עם בעלי דירות נוספים. בע"א 395/74 יצחק לוי, ואח' נ' רבקה סמואל, ואח' פד"י כ"ט (2) 43,39, נאמר בהקשר זה כי- **"בדרך כלל מתקבל על הדעת שהוספת דירות בבית משותף עשויה לגרום להורדת ערך יתר הדירות בבית, במידה מרובה או מועטה"**. בת"א (ת"א) 2523/07, בנימין נ' ירושלמי [פורסם ב"נבו"], 6.4.10, נאמר כי **"פיצול דירה למספר יחידות עצמאיות ללא היתר, מבלי שנשקלו השיקולים התכנוניים, מביא לעומס גדול יותר על התשתיות שתוכננו מלכתחילה עבור הבית המשותף – מנגנוני התפעול המרכזיים של הבניין : עומס גדול יותר על מקומות החניה**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המועטים המותקנים, על תשתיות המים והביוב כתוצאה מתוספת מקלחונים, שירותים והכנת תשתית מטבחים, על המעליות. תנועה גדולה יותר של דיירים עלולה לגרום למטרד של רעש ולכלוך עבור הדיירים, ועלולה לגרום לירידת ערך הדירות בבניין המשותף".

80. במקרה הנדון הוכח כי שכטר אכן פיצלו את דירתם לאחר הרחבתה לשתי יחידות נפרדות: שכטר אישרה כי הרחבת הדירה, היינו חלקה העליון שנבנה על פני גג הקומה השלישית כולל "שירותים ומטבחון קטן" וכי יחידה זו סגורה בדלת "פלדלת" בניגוד ליתר החדרים בבית (ראה עמ' 23 שורות 35-30). על אף טענת שכטר כי לא פיצלו דירתם, עומתה ציפורה שכטר בעדותה עם תמונה ממנה עולה כי בתקופה מסוימת היה תלוי שלט בשם "בלומשטיין" על דלת הפלדלת. שכטר טענה כי אינה זוכרת מתי שלט זה הוסר (ראה עמ' 23 שורה 37). בעוד שבתחילה טענה כי בלומשטיין הם "ידידים של בעלי שאפשרנו לה להיות שם בבית שלנו לתקופה של כמה שבועות" וכי הם "לא שילמו", ציינה בהמשך עדותה, ביחס לתשלום, כי "אני לא יודעת, אולי בעלי עשה אתם הסכם" (ראה עמ' 23 שורות 49-48, עמ' 24 שורות 3-1). עדותה של שכטר בכל הנוגע לטענתה כי הדירה לא פוצלה כלל לא הותירה רושם מהימן ומתשובותיה עולה תמונה לפיה אכן משמשת תוספת הבניה לדירתם במפלס העליון כיחידה נפרדת. יתרה מכך. שכטר בחרו שלא להתייבב לביקור במקום ובכך מנעו את האפשרות לבחון את טענתם כי הדירה לא פוצלה ומשמשת יחידה שלמה אחת. הימנעותם מלהגיע לביקור משמשת כנגדם, מחלישה את טענתם ומחזקת את המסקנה כי דירתם אכן פוצלה לשתי יחידות דיור נפרדות.

81. בביקור שערכתי במקום הייתה דלת הכניסה לדירת שכטר בקומה שלישית סגורה ואילו בקומה הרביעית-פתוחה. כניסה בדלת זו הובילה למדרגות בהן ניתן היה להבחין בשתי דלתות. מעדות שכטר עולה כי למעשה אחת הדלתות משמשת ככניסה ליחידה הנפרדת והשנייה לדירת שכטר.

82. פיצול דירת שכטר לשתי יחידות נפרדות אכן מהווה פגיעה בדירת התובעת כפי טענתה שכן חזקה כי יש בה כדי להשפיע על עומס בתשתיות הקיימות ובמקומות חניה. פיצול זה, יש לזכור, נעשה גם מבלי שבעלי הדירות התבקשו ליתן הסכמתם לכך, שכן הסכמתם ניתנה להרחבת דירת שכטר בלבד. במצב דברים זה נאסר על שכטר לפצל את דירתם לשתי יחידות ולעשות שימוש נפרד בהרחבת דירתם או בכל חלק אחר ממנה כיחידה נפרדת. כמו כן אני מורה לשכטר לבטל כל קיר מפריד הקיים בדירתם בין הדירה המקורית להרחבה הממוקמת בקומה הרביעית. על ההרחבה להוות חלק בלתי נפרד מדירתם ללא מחיצות. די באמור כדי למנוע משכטר להמשיך ולפצל את דירתם המורחבת לשתי יחידות נפרדות ואיני מוצאת ליתן סעדים נוספים בעניין. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

תביעה שכנגד

83. דינה של התביעה שכנגד, אותה הגיש ורצברגר כנגד שרה נפחא, להידחות. ראשית, המחסן ביחס אליו נטען כי הנתבעת שכנגד תפסה חזקה ייחודית התברר כלא יותר ממדף צר הממוקם בקומה השלישית של הבית המשותף בסמוך ליציאה לגג, בו מצוידים חפצים (כפי שהתרשמתי בביקור במקום וכן כעולה מהתמונות-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נספח א' לכתב ההגנה שכנגד). שנית, במהלך הדיון התברר כי הנתבעת שכנגד כלל לא עושה בו שימוש ייחודי, שכן ורצברגר עצמו הודה בחקירתו כי הוא מאפסן שם את ציוד הסוכה שלו. כשנשאל האם נכון שיש על מדף זה "גם דברים שלך" השיב כי: "אולי שלושה חבילות סכך" ובהמשך אישר כי מאוחסנים שם גם "שניים שלושה קורות" שלו (ראה פרוט' 10.9.19 עמ' 17 שורות 44,40). ורצברגר הסתיר בכתב תביעתו את העובדה כי גם הוא מאחסן במדף חפצים וזאת בחוסר תום לב. כשנשאל מדוע השמיט פרט זה מכתב התביעה שהגיש השיב: "אין לי תשובה" (עמ' 17 שורות 49-48). הודאה זו מאיינת מאליה את טענת השימוש הייחודי.

84. טענה נוספת שהועלתה בכתב התביעה היא כי הנתבעת שכנגד מונעת מורצברגר לבנות סוכה על הגג שמעל דירתה ונוהגת להקים שם סוכה בעצמה. לפיכך נטען כי יש לאסור על הנתבעת שכנגד להקים סוכה בגג שמעל דירתה. גם דין טענה זו להידחות. זה מכבר נפסק כי בניית סוכה לימי חג הסוכות מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף וכי אין מדובר בשימוש ייחודי (ראה: רע"א 8834/12, מ.ע.ג.ן ייעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' מרסה [פורסם ב"נבו"], 31.12.12).

ח. סוף דבר

85. התביעה מתקבלת והתביעה שכנגד- נדחית, כמפורט להלן:

86. נאסר בזאת על הנתבעים 1-2, או מי מטעמם, לבנות יחידות דיור נפרדות בגג המשותף, או בכל שטח משותף אחר, לרבות על פי התכנית החדשה, או כל תכנית אחרת, כל עוד אין בידם את הסכמת כל בעלי הדירות כדין ובכלל זה הסכמת התובעת בכתב. למען הסר ספק יובהר כי אין בכך בכדי למנוע בניית הרחבות דירה (כהגדרתה של הרחבת דירה לעיל) לפי תכניות אלו (ובכפוף לקבלת היתר בניה כדין).

87. על הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, להרוס בתוך 90 יום מיום קבלת פסק הדין, את היחידה אשר נבנתה בגג המשותף (בחלקה מעל דירת ורצברגר ובחלקה מעל דירת שכטר) ולהותיר את הגג פנוי בשטח בו נבנתה יחידה זו מכל חפץ.

88. נאסר על שכטר לפצל את דירתם לשתי יחידות ולעשות שימוש נפרד בהרחבת דירתם או בכל חלק אחר ממנה כיחידה נפרדת. כמו כן אני מורה לשכטר לבטל כל קיר מפריד הקיים בדירתם בין הדירה המקורית להרחבה הממוקמת בקומה השלישית. על ההרחבה להוות חלק בלתי נפרד מדירתם ללא מחיצות. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

89. בשים לב לתוצאת ההליך, מורכבותו והיקפו, הנתבעים 1-2 יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת ושכר טרחת עורך דינה בסך כולל של 25,000 ₪. הנתבעים 3-4 יישאו בהוצאות התובעת ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ש"ח. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום ולאחר מכן יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/103/2017, 1/174/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן היום, כ"ב אב תש"ף, 12 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין